



MÉRITO

TRIBUNAL PLENO – SESSÃO DE 05/02/2025 – SECÇÃO MUNICIPAL

CAUTELAR EM PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO

Processo: TC-024439.989.24-5.

Representante: Rafael Augusto Prodóssimo da Silva (OAB/SP n.º 379.249).

Representada: Prefeitura Municipal de Brodowski.

Responsáveis: - José Luiz Perez, Prefeito à época da subscrição do edital; e
- Fábio Maximiniano Vercezi Severi, Prefeito.

Advogado: Eliezer Pereira Martins (OAB/SP n.º 168.735).

Assunto: Representação formulada contra o edital da Concorrência Pública n.º 003/2023, Processo n.º 0596/2023, visando à concessão administrativa para a modernização, otimização, expansão, operação e manutenção da infraestrutura da rede de iluminação pública do Município de Brodowski.

Senhor Presidente, Senhores Conselheiros, Senhora Procuradora do Ministério Público de Contas,

Trata-se de Representação de autoria do advogado **Rafael Augusto Prodóssimo da Silva** contra o edital da Concorrência Pública n.º 003/2023, Processo n.º 0596/2023, da Prefeitura de Brodowski, visando à concessão administrativa para a modernização, otimização, expansão, operação e manutenção da infraestrutura da rede de iluminação pública do Município.

Em resumo, o impugnante, após chamar atenção para o momento em que o certame é realizado, no final do mandato do Chefe do Executivo, insurge-se contra as seguintes particularidades do ato de chamamento:



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Gabinete da Conselheira CRISTIANA DE CASTRO MORAES



a) carência de lei autorizativa para a delegação almejada, em violação ao artigo 2º, *caput*, da Lei Federal n.º 9.074/1995 e ao artigo 38, parágrafo único, da Lei Orgânica do Município. Destaca que, no documento denominado “Estudo de Modelagem Jurídica”, tece-se argumentação no sentido de que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo teria, em ação de controle concentrado (ADI 2025560-75.2021.8.26.0000), reconhecido a inconstitucionalidade de comandos que faziam esta requisição em situações da espécie. Registra, no entanto, que “*autorização legislativa*” não se confunde com “lei legislativa”, assim como que o inciso VII do parágrafo único do artigo 38 da Lei Orgânica¹ permanece em vigor, colacionando excertos da referida decisão judicial e quadro com as normas impactadas. Consigna que, na mesma ocasião, o Tribunal de Justiça reconheceu expressamente a constitucionalidade do citado dispositivo, assim como de norma que vedava a concessão de serviços públicos de saneamento básico, tudo a confirmar, a seu ver, a necessidade de lei autorizativa para a presente delegação²;

¹ Art. 38 As leis complementares, para sua aprovação, exigem o voto favorável da maioria absoluta dos membros da Câmara.

Parágrafo único. São leis complementares as concernentes às seguintes matérias:

[...]

VII - concessão de serviço público;

² Assim, sumariza suas conclusões:

“(i) A Lei 9.074/1995 determina em seu artigo 2º, ‘caput’, que cabe ao Município estabelecer, em sua Lei Orgânica, as hipóteses em que não será necessária lei autorizativa;

(ii) A Lei Orgânica de Brodowski determina, no inciso VII do parágrafo único do artigo 38, que compete à Câmara editar Lei Complementar a relativa à concessão de serviço público;

(iii) O documento intitulado “Estudo de Modelagem Jurídica” tenta fazer um malabarismo retórico, invocando a ADI - 2025560- 75.2021.8.26.0000 e afirmando que ela declarou inconstitucional a necessidade de lei autorizativa, tirando dessa ADI o fundamento de sua tese de que não é necessária lei autorizativa;

(iv) A ADI - 2025560-75.2021.8.26.0000, ao contrário do que afirma o Município, nunca declarou inconstitucional a necessidade de lei autorizativa, mas tão somente a expressão “autorização legislativa”, que não é sinônima de “lei autorizativa”.

(v) Finalmente, a ADI - 2025560-75.2021.8.26.0000 afirmou a constitucionalidade do inciso VII do parágrafo único do artigo 38 da Lei Orgânica de Brodowski, e também declarou constitucional lei que proibia a concessão de saneamento.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Gabinete da Conselheira CRISTIANA DE CASTRO MORAES



b) críticas às parcelas de maior relevância e valor significativo eleitas para fins de qualificação técnica³, na seguinte conformidade:

(b.1) subitem 14.4.1.1.⁴ – requisição de expertise técnica em atividades de (i) operação e manutenção e rede de iluminação pública, acompanhada do fornecimento (ii) da mão de obra e (iii) da integralidade dos materiais, a qual é abusiva e restringe a competitividade, pois as tarefas possuem naturezas diversas e podem ser prestadas por diferentes empresas. Aduz que, na forma como redigida a imposição, ainda que esteja permitida a reunião de interessadas em consórcio, haverá a necessidade de a experiência em relação a todos os aspectos previstos ser comprovada por uma única integrante do grupo;

(b.2) subitem 14.4.1.2.⁵ – (i) solicitação de evidenciação de anterior instalação de luminárias especificamente de tecnologia LED, cuja realização não apresenta diferenças significativas em relação a outros tipos de lâmpadas; e (ii) requisição de que a comprovação ocorra em sistemas de iluminação de natureza pública, impedindo a evidenciação como serviços prestados em espaços particulares; e

(b.3) subitem 14.4.1.3.⁶ – exigência de execução pretérita de iluminação artística, ornamental e decorativa em monumentos históricos, ilegal, limitadora da disputa e sem relevância para o conjunto da contratação; e

(vi) FINALMENTE – provamos detalhadamente que é sim necessária lei autorizativa para a concessão de serviços públicos.

(vii) A LICITAÇÃO É ILEGAL.

³ 14.4.1. A LICITANTE ou ao menos uma das CONSORCIADAS deverá comprovar, por meio de atestados emitidos por entidades públicas ou privadas, sua expertise, para execução de atividades com características técnicas similares e de maior relevância às atividades operacionais, no âmbito da CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, quais sejam:

⁴ 14.4.1.1. operação e manutenção de rede de iluminação pública com, no mínimo 2.198 (dois mil cento e noventa e oito), pontos de iluminação instalados concomitantes, com fornecimento de mão de obra e da integralidade dos materiais;

⁵ 14.4.1.2. execução de obras e serviços de ampliação, ou reforma ou efficientização/otimização energética de sistema(s) de iluminação pública, com instalação de luminárias, por meio da utilização de tecnologia Light Emitting Diode (LED);

⁶ 14.4.1.3. implantação de pontos de iluminação pública artística / ornamental / decorativa de monumentos históricos.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Gabinete da Conselheira CRISTIANA DE CASTRO MORAES



c) demanda por assinatura de documentos por contador registrado no Conselho Regional de Contabilidade, em vulneração ao § 1º do artigo 69 da Lei Federal n.º 14.133/2021⁷.

Em conclusão, requer a concessão de medida liminar de paralisação do torneio, a fim de que seja determinado o aprimoramento do ato convocatório nas particularidades combatidas.

Vislumbaram-se, ao menos em tese, potenciais vulnerações à higidez da licitação, nisso se incluindo aspecto adicional àqueles suscitados na inicial⁸, em

⁷ 14.2.9.1. Em se tratando de sociedades limitadas, os balanços e as demonstrações poderão ser apresentados: (i) por fotocópia do livro diário, inclusive com os termos de abertura e de encerramento, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da LICITANTE ou da CONSORCIADA ou em outro órgão equivalente; ou (ii) por fotocópia do balanço e das demonstrações contábeis devidamente registrados na Junta Comercial da sede ou domicílio da LICITANTE ou da CONSORCIADA, datados e assinados pelo responsável da empresa, e por profissional de contabilidade habilitado e devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade – CRC; ou (iii) por documento emitido via internet do balanço e das demonstrações contábeis, desde que assinados digitalmente pelo responsável pela sociedade e por profissional devidamente registrado no CRC, em conjunto com o comprovante de entrega digital.

14.2.9.2. Em se tratando de sociedades regidas pela Lei Federal nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, os balanços deverão ser apresentados por meio de publicações, na forma dos arts. 289 e 294 da Lei Federal nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 e Portaria nº 12.071, de 7 de outubro de 2021, do Ministério da Economia, conforme o caso.

14.2.9.2.1. Os balanços exigidos pelo item 14.2.9.2 deverão estar aprovados por assembleia geral ordinária ou extraordinária, cujas atas devem estar devidamente registradas na Junta Comercial e publicada na forma dos arts. 289 e 294 da Lei Federal nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 e Portaria nº 12.071, de 7 de outubro de 2021 do Ministério da Economia, conforme o caso.

14.2.9.3. Em se tratando de fundos de investimento, os balanços patrimoniais e as demonstrações contábeis deverão (i) estar assinados pelo representante legal do fundo e por profissional de contabilidade registrado no Conselho Regional de Contabilidade – CRC; (ii) estarem auditados por empresa de auditoria independente; e (iii) estar arquivados na CVM.

⁸ “[...] Vislumbra-se, ao menos em tese, potencial vulneração à higidez da licitação, em desatenção às normas de regência da matéria.

De fato, **sem prejuízo da oportuna análise de todos os aspectos suscitados na inicial**, verifica-se, em consulta ao Diário Oficial do Município de Brodowski (Edição n.º 1217 – 02/12/2024), que, em análise de impugnação administrativa, a Prefeitura optou por excluir a exigência de qualificação técnica prevista no subitem 14.4.1.3 do instrumento, tema objeto de questionamento nos presentes autos.

Ocorre que tal providência não foi acompanhada da devolução de prazo para formulação das propostas, o que soa, em análise apriorística, contrariar a regra do § 1º do artigo 55 da Lei Federal n.º 14.133/2021, porquanto a mudança, ao flexibilizar as solicitações da aferição da aptidão técnica das interessadas, possibilita, em tese, o ingresso de novos competidores.

Nesse sentido, confira-se a decisão proferida no bojo dos processos n.ºs TC-023042.989.22-8, TC-



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Gabinete da Conselheira CRISTIANA DE CASTRO MORAES



desatenção às normas de regência da matéria.

Por esses motivos, com fundamento no § 2º do artigo 171 da Lei n.º 14.133/2021, assinalou-se à autoridade responsável interregno para o encaminhamento de cópia integral do instrumento censurado, assim como para o oferecimento de justificativas.

No interesse da lisura da licitação e, considerando que este Tribunal poderá decidir pela alteração da peça editalícia, determinou-se a suspensão do procedimento questionado até apreciação final dos temas.

Adequadamente notificada, a Representada juntou ao presente feito documentos e esclarecimentos de seu interesse.

Salientando que o ato de chamamento observou, na íntegra, a legislação incidente, destaca que a deflagração deste torneio foi precedida de amplo estudo técnico e da devida publicidade, tendo havido Manifestação de Interesse, bem como Consulta e Audiência Públicas, na esteira do anunciado no preâmbulo da peça bora questionada.

Por outro lado, compreende que houve confusão entre os conceitos de autorização legislativa prévia para a outorga ou delegação dos serviços e a regulação das concessões de que trata o artigo 38, inciso VII, da Lei Orgânica do Município.

Sobre isso, alude que, *Em outras palavras, em que pese o reconhecimento da constitucionalidade do dispositivo supramencionado, o mesmo é voltado para a exigência de que matérias que regulamentam as concessões de*

023199.989.22-9 e TC-023307.989.22-8, sob minha relatoria, em Sessão Plenária de 08/03/2023.

Ainda, merece esclarecimentos da Origem a adoção, como base de cálculo do capital social ou patrimônio líquido mínimo que deverá ser demonstrado, para fins de qualificação econômico-financeira, do valor estimado do contrato obtido a partir do **somatório das quantias máximas previstas para a contraprestação** durante toda a vigência da avença – e **não do montante equivalente aos investimentos** a ser despendidos pela futura concessionária -, definição que igualmente aparente frustrar orientação jurisprudencial prevalente nesta Corte, ilustrada pelo julgamento do processo n.º TC-011912.989.20-9, em Sessão Plenária de 22/07/2020, sob relatoria do e. Conselheiro Antonio Roque Citadini [...].



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Gabinete da Conselheira CRISTIANA DE CASTRO MORAES



serviços públicos sejam reservadas as Leis Complementares, em nada se confundindo, repisa-se, com a necessidade de autorização legislativa prévia para a concessão de serviços públicos.

De todo modo, considera que a discussão correspondente perdeu seu objeto, eis que, *in casu*, houve a devida autorização legislativa para a realização do presente certame, conforme se infere da Lei Complementar Municipal n.º 376/2024.

Delineia, ademais, que os requisitos destacados para comprovação da aptidão técnica atendem ao disposto no artigo 67 da Lei n.º 14.133/2021.

Especificamente em relação à parcela de maior relevância consistente na prova de implantação anterior de pontos de iluminação pública artística/ornamental/decorativa de monumentos históricos, explica que, acatando impugnação administrativa, deixou de exigi-la; reconhecendo, de outro lado, que, ao agir dessa forma, não devolveu o interregno para a formalização das propostas, providência que será tomada por ocasião da retomada da competição.

Pontua que o quantitativo mínimo de demonstração de capacitação técnica, demandado apenas para o subitem 14.4.1.1 – operação e manutenção da rede de iluminação –, mostra-se condizente com a limitação do artigo 67, § 2º, da Lei n.º 14.133/2021.

Dispõe que *considerando-se que o escopo da presente licitação prevê a modernização da rede de iluminação do Município [...], resta demonstrada a pertinência na exigência de que os proponentes comprovem suas aptidões técnicas através de experiência anterior com a utilização da tecnologia a ser empregada na execução do objeto.*

Sobre a solicitação de prova de execução de obras e serviços de ampliação, ou reforma ou efficientização/otimização energética de sistema(s) de iluminação pública, com instalação de luminárias, por meio da utilização de tecnologia Light Emitting Diode (LED), realça que basta à proponente a simples execução pretérita da atividade, ainda que em quantitativo mínimo.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Gabinete da Conselheira CRISTIANA DE CASTRO MORAES



Aduz que a exigência de que os documentos contábeis sejam assinados por contador habilitado está consonante com o artigo 69, § 1º, do Novo Estatuto Licitatório e o artigo 1.184, § 2º, do Código Civil.

No que tange à base de cálculo para o demonstrativo da qualificação econômico-financeiro, pondera que o ato de chamamento atende às prescrições do artigo 69, § 4º, da Nova Lei de Licitações e Contratos.

Pleiteia, assim, a improcedência dos presentes reclamos, com consequente revogação da cautelar determinativa de paralisação do torneio.

A **ATJ**, conjugados os aspectos **técnicos e jurídicos** da matéria, com o endosso de sua **Chefia**, posiciona-se pela **parcial procedência** das insurgências, assim como pela **pertinência** da particularidade suscitada na decisão concedente da cautelar de suspensão da Concorrência em apreço.

Em mesmo sentido os pareceres do **MPC** e **SDG**.

É o relatório.

GC.CCM-21



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Gabinete da Conselheira CRISTIANA DE CASTRO MORAES



MÉRITO

TRIBUNAL PLENO – SESSÃO DE 05/02/2025 – SECÇÃO MUNICIPAL

CAUTELAR EM PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO

Processo: TC-024439.989.24-5.

Representante: Rafael Augusto Prodóssimo da Silva (OAB/SP n.º 379.249).

Representada: Prefeitura Municipal de Brodowski.

Responsáveis: - José Luiz Perez, Prefeito à época da subscrição do edital; e
- Fábio Maximiniano Vercezi Severi, Prefeito.

Advogado: Eliezer Pereira Martins (OAB/SP n.º 168.735).

Assunto: Representação formulada contra o edital da Concorrência Pública n.º 003/2023, Processo n.º 0596/2023, visando à concessão administrativa para a modernização, otimização, expansão, operação e manutenção da infraestrutura da rede de iluminação pública do Município de Brodowski.

EMENTA: CAUTELAR EM PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO. LICITAÇÃO. CONCORRÊNCIA PÚBLICA. CONCESSÃO ADMINISTRATIVA PARA A MODERNIZAÇÃO, OTIMIZAÇÃO, EXPANSÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE BRODOWSKI. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA. MODIFICAÇÃO EDITALÍCIA POR OCASIÃO DA APRECIAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA. DEVOLUÇÃO DE PRAZO PARA A PREPARAÇÃO DAS PROPOSTAS. CARÊNCIA. REQUISICÃO DE PROVA DE EXPERIÊNCIA ANTERIOR EM ATIVIDADES ESPECÍFICAS. AFRONTA À SÚMULA N.º 30. CAPITAL SOCIAL OU PATRIMÔNIO LÍQUIDO. BASE DE CÁLCULO. VALOR ESTIMADO PARA A CONTRATAÇÃO. INADEQUAÇÃO. SÚMULA N.º 43. PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECOMENDAÇÕES.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Gabinete da Conselheira CRISTIANA DE CASTRO MORAES



Senhor Presidente, Senhores Conselheiros, Senhora Procuradora do Ministério Público de Contas,

De início, solicito referendo deste Plenário para as medidas preliminares adotadas no sentido da requisição de documentos e justificativas e determinação de suspensão do procedimento, propondo o recebimento deste feito como Cautelar em Procedimento de Contratação.

No mérito, em harmonia com a posição uniforme dos órgãos oficiantes nos autos, evidencia-se a **parcial procedência** da Representação e a **pertinência** do ponto levantado por ocasião da concessão da medida cautelar de paralisação da presente disputa.

Iniciando-se pelos questionamentos despidos de fundamento, tem-se, em sede de qualificação econômico-financeira, que as assinaturas requisitadas nos subitens 14.2.9.1. e 14.2.9.3.⁹ são do *profissional de contabilidade registrado no Conselho Regional de Contabilidade – CRC*, não especificamente do *contador*, o que se alinha ao entendimento desta Corte acerca da matéria, ilustrado no julgamento do TC-018445.989.24-7 (Sessão Plenária de 23/10/2024, sob minha relatoria), cujo excerto é de oportuna transcrição:

[...] Ainda sob o prisma da qualificação econômico-financeira, a demanda por oferta de balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis assinadas pelo contador responsável da empresa (subitem 6.4.4) não encontra respaldo na legislação de

⁹ “14.2.9.1. Em se tratando de sociedades limitadas, os balanços e as demonstrações poderão ser apresentados: (i) por fotocópia do livro diário, inclusive com os termos de abertura e de encerramento, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da LICITANTE ou da CONSORCIADA ou em outro órgão equivalente; ou (ii) por fotocópia do balanço e das demonstrações contábeis devidamente registrados na Junta Comercial da sede ou domicílio da LICITANTE ou da CONSORCIADA, datados e assinados pelo responsável da empresa, e por profissional de contabilidade habilitado e devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade – CRC; ou (iii) por documento emitido via internet do balanço e das demonstrações contábeis, desde que assinados digitalmente pelo responsável pela sociedade e por profissional devidamente registrado no CRC, em conjunto com o comprovante de entrega digital.

[...]

14.2.9.3. Em se tratando de fundos de investimento, os balanços patrimoniais e as demonstrações contábeis deverão (i) estar assinados pelo representante legal do fundo e por profissional de contabilidade registrado no Conselho Regional de Contabilidade – CRC; (ii) estarem auditados por empresa de auditoria independente; e (iii) estar arquivados na CVM”.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Gabinete da Conselheira CRISTIANA DE CASTRO MORAES



regência, notadamente no disposto no § 2º do artigo 12 do Decreto-Lei nº 9.295/46, após as modificações empreendidas pela Lei Federal nº 12.249/10¹⁰, tal como delineado por ocasião do julgamento dos processos n.ºs TC-008865.989.17-2, TC-008883.989.17-0, TC-008896.989.17-5 e TC-008928.989.17-7¹¹:

[...] **2.6** Considero procedente o questionamento quanto à exigência de balanço patrimonial contábil assinado por contador, uma vez que o inciso I do artigo 31 da Lei nº 8.666/93 tece as seguintes exigências:

“I – balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;” (Grifei)

Quanto ao tema, a Lei federal nº 6.404/76, no § 4º do artigo 177 prescreve o seguinte:

“ § 4º As demonstrações financeiras serão assinadas pelos administradores e por contabilistas legalmente habilitados.” Grifei.

Por sua vez, na Lei federal nº 10.406/02, o assunto é abordado no §2º do artigo 1.184, da seguinte forma:

“§ 2º Serão lançados no Diário o balanço patrimonial e o de resultado econômico, devendo ambos ser assinados por técnico em Ciências Contábeis legalmente habilitado e pelo empresário ou sociedade empresárias.” (Grifei)

Dessa forma, o balanço patrimonial deve ser assinado por contabilista legalmente habilitado, sendo representado tanto por contador, como por técnico em contabilidade, neste caso, registrado no Conselho Regional de Contabilidade até 1º de junho de 2015, nos termos do artigo 76 da Lei federal nº 12.249/10, que alterou o Decreto-Lei nº 9.295/46 [...].

Em caminho análogo as decisões proferidas no processo n.º TC-009833.989.22-1, sob relatoria do e. Conselheiro Robson Marinho, em Sessão Plenária de 08/06/2022; processos n.ºs TC-020504.989.20-3 e TC-020700.989.20-5, sob relatoria do e. Substituto de Conselheiro Alexandre Manir Figueiredo Sarquis, em Sessão Plenária de 30/09/2020; assim como no processo n.º TC-026225.989.19-3, em Sessão Plenária de 12/02/2020, sob relatoria do e. Conselheiro Sidney Estanislau Beraldo.

Logo, compete à Origem permitir que as peças contábeis relacionadas no edital sejam assinadas por contabilista legalmente habilitado, expressão que deve abarcar tanto o contador, como o técnico em contabilidade, esse último registrado no Conselho Regional de Contabilidade até 1º de junho de 2015, nos termos do artigo 76 da Lei federal nº 12.249/2010, que

¹⁰ “Art. 12. Os profissionais a que se refere este Decreto-Lei somente poderão exercer a profissão após a regular conclusão do curso de Bacharelado em Ciências Contábeis, reconhecido pelo Ministério da Educação, aprovação em Exame de Suficiência e registro no Conselho Regional de Contabilidade a que estiverem sujeitos.

[...]

§ 2º Os técnicos em contabilidade já registrados em Conselho Regional de Contabilidade e os que venham a fazê-lo até 1º de junho de 2015 têm assegurado o seu direito ao exercício da profissão”.

¹¹ “Sessão Plenária de 26/07/2017, sob relatoria do e. Conselheiro Dimas Ramalho”.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Gabinete da Conselheira CRISTIANA DE CASTRO MORAES



modificou o Decreto-Lei nº 9.295/1946.

À vista disso e tendo em conta, por analogia, o disposto no artigo 69, § 1º, da Lei n.º 14.133/2021¹², diploma esse que rege, subsidiariamente, este torneio, revela-se improcedente a crítica que recai nessas particularidades do instrumento, cabendo, no entanto, asseverar a Origem para o fato de que a expressão *profissional de contabilidade registrado no Conselho Regional de Contabilidade* deve, necessariamente, abarcar, como destacado no precedente colacionado, *tanto o contador, como o técnico em contabilidade, esse último registrado no Conselho Regional de Contabilidade até 1º de junho de 2015, nos termos do artigo 76 da Lei federal nº 12.249/2010, que modificou o Decreto-Lei nº 9.295/1946.*

Igualmente, saliente-se que a Lei Complementar local n.º 376, de 11 de junho de 2024, dedicou-se a autorizar o *Poder Executivo a delegar, por meio de parceria público-privada, a prestação de serviços relativos à modernização, otimização, expansão, operação e manutenção da infraestrutura da rede de iluminação pública do Município de Brodowski*, constata-se essa que, por si só, sobretudo em face do figurino estreito dos processos vocacionados às cautelares em procedimentos de contratação, afasta a queixa que se ressentir de tal normativo.

Nada obstante, em linha com o *Parquet* de Contas e a Secretaria-Diretoria Geral, convém recomendar à Representada que, por ocasião de eventual relançamento da competição, indique no rol informativo da legislação regente do procedimento a sobredita norma complementar municipal, bem como o sítio eletrônico em que ela pode ser consultada.

Já no que se refere ao tópico da qualificação técnica, as correspondentes censuras demandam avaliações individualizadas, dados os diferentes aspectos contra os quais se investem.

¹² “§ 1º A critério da Administração, poderá ser exigida declaração, assinada por profissional habilitado da área contábil, que ateste o atendimento pelo licitante dos índices econômicos previstos no edital”.



Nesse sentido, tal como registrado no bojo da decisão concessora da cautelar de paralisação desta Concorrência, a Municipalidade procedeu à exclusão da parcela de maior relevância anteriormente delineada no subitem 14.4.1.3. do instrumento, consistente na prova de pretérita *implantação de pontos de iluminação pública artística / ornamental / decorativa de monumentos históricos*, consoante resultado de análise de impugnação elaborada diretamente na via administrativa, divulgado no Diário Oficial do Município de Brodowski (Edição n.º 1217, de 02/12/2024, p. 6).

Ocorre que o próprio órgão promotor desta disputa reconheceu, em suas razões defensórias, que referida modificação editalícia não se fez acompanhar da necessária devolução de lapso temporal para a preparação das propostas, em afronta ao artigo 55, § 1º, da Lei n.º 14.133/2021¹³, porquanto essa alteração, representando flexibilização das solicitações vocacionadas à aferição da capacitação técnica, tinha o condão de ampliar o universo competitivo.

A reforçar essa conclusão, o julgamento proferido nos autos dos Processos n.ºs TC-023042.989.22-8, TC-023199.989.22-9 e TC-023307.989.22-8 (Sessão Plenária de 08/03/2023, sob minha relatoria).

Isso, contudo, consubstancia perspectiva prejudicada pela ordem de suspensão do torneio, mas que, consigne-se, deverá ser observado pela Prefeitura na hipótese de retomada do intento de contratação.

Em continuidade, quanto à solicitação de evidenciação de prévia *execução de obras e serviços de ampliação, ou reforma ou efficientização/otimização energética de sistema(s) de iluminação pública, com instalação de luminárias, por meio da utilização de tecnologia Light Emitting Diode (LED)* (subitem 14.4.1.2.), a reclamação correlata, em qualquer das perspectivas em que foi elaborada, revela-se procedente.

¹³ “§ 1º Eventuais modificações no edital implicarão nova divulgação na mesma forma de sua divulgação inicial, além do cumprimento dos mesmos prazos dos atos e procedimentos originais, exceto quando a alteração não comprometer a formulação das propostas”.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Gabinete da Conselheira CRISTIANA DE CASTRO MORAES



Desse modo, segundo verificação empreendida pelo setor competente de ATJ, estão em descompasso com o artigo 67, inciso II, da Lei n.º 14.133/2021 e a Súmula n.º 30 desta Corte as imposições de que as atividades relacionadas no sobredito dispositivo editalício envolvam a *instalação de luminárias, por meio da utilização de tecnologia LED*, bem como a de que tenham sido realizadas, necessariamente, em *sistema(s) de iluminação pública*, isso independentemente da não estipulação de quantitativo mínimo.

Com efeito, em conformidade com o parecer técnico-especializado - cujo excerto está reproduzido, em parte, na sequência –, não se identifica diferencial na instalação de luminárias mediante emprego de tecnologia “LED” em comparação com as demais soluções disponíveis no mercado. De mesma forma, a demanda de que a comprovação em tela esteja necessariamente ligada a sistema público, sem permissão, portanto, de que recaia em empreendimentos privados, caracteriza exigência de demonstração de atuação pretérita em serviço específico:

[...] Como bem delineado pelo Representante, o subitem 14.4.1.2 do corpo do edital (transcrito a seguir) restringe a prova de aptidão técnica das empresas/consórcios às obras e serviços que envolvam a instalação de luminárias necessariamente com a tecnologia LED e realizadas em ambiente exclusivamente público:

14.4. Qualificação Técnica:

14.4.1. A LICITANTE ou ao menos uma das CONSORCIADAS deverá comprovar, por meio de atestados emitidos por entidades públicas ou privadas, sua expertise, para execução de atividades com características técnicas similares e de maior relevância às atividades operacionais, no âmbito da CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, quais sejam:

[...] 14.4.1.2. execução de obras e serviços de ampliação, ou reforma ou eficiência/otimização energética de sistema(s) de iluminação pública, com instalação de luminárias, por meio da utilização de tecnologia Light Emitting Diode (LED).

[...]

Na minha concepção, a Entidade Concedente deixou de demonstrar tecnicamente que a experiência prévia na implantação de luminárias com a especificação de tecnologia LED seja indispensável para fins de habilitação.

Tal como pontuado pelo Impugnante, não se vislumbra diferencial relevante na experiência de implantação de luminárias de LED em comparação com outras tecnologias, a exemplo de vapor de sódio, vapor metálico etc.

Nessa toada, o inc. II do art. 67 do novel diploma regente das licitações e



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Gabinete da Conselheira CRISTIANA DE CASTRO MORAES



contratos¹⁴ estabelece que a comprovação da capacitação técnico-operacional (ou qualificação operacional, na nomenclatura da Lei Federal n. 8.666/93) é demonstrada pela execução de serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior.

Consequentemente, creio que a experiência anterior em obras e serviços similares de implantação de luminárias com outras tecnologias usuais (vapor de sódio, vapor metálico etc.) também se presta a comprovar a aptidão técnica da empresa/consórcio licitante para executar o objeto pretendido.

Não se olvida que todos os serviços devam ser prestados adequadamente para a escorreita consecução do objeto pactuado. Isso não autoriza que todos sejam requeridos como condição de habilitação, posto que o art. 37, inc. XXI, da Constituição Federal¹⁵ somente autoriza as exigências de qualificação técnica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.

Na mesma direção, conflui a remansosa jurisprudência desta e. Corte, exemplificada pelas seguintes rr. Decisões em sede de Exame Prévio de Edital:

TC-008481.989.22-6 (Sessão do E. Pleno de 13/04/2022):

[...] Embora tenha tentado inicialmente defender a regularidade da pormenorização, a Municipalidade concorda em retirar da tecnologia LED a exclusividade para fins de aferição da qualificação técnica, o que torna a matéria incontroversa, resolvendo-a em harmonia com o entendimento jurisprudencial atualmente prevalente neste Tribunal.

TC-023188.989.21-4 (Sessão do E. Pleno de 02/02/2022):

[...] No exame de editais de licitação divulgados para contratação de serviços relacionados à manutenção, conservação e/ou melhorias da rede de iluminação pública municipal, a orientação deste E. Tribunal tem reprovado a condição de habilitação que pressuponha a demonstração de experiência no fornecimento de luminárias na tecnologia “led”, tendo em vista a proibição de comprovação de experiência em atividade específica, conforme enunciado nº 30 da nossa Súmula de jurisprudência.

É bem verdade que, desde o prazo final da encampação dos ativos de iluminação pública pelos municípios em todo o país – encerrado em 2014 por força da Resolução Normativa nº 414/10 e da Resolução Normativa Aneel nº 479/12 – e a consequente ampliação da demanda até os dias atuais, não seria desarrazoado supor a evolução da oferta para tornar mais acessíveis as tecnologias

¹⁴ “Art. 67. A documentação relativa à qualificação técnico-profissional e técnico-operacional será restrita a: [...] II - certidões ou atestados, regularmente emitidos pelo conselho profissional competente, quando for o caso, que demonstrem capacidade operacional na execução de serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior, bem como documentos comprobatórios emitidos na forma do § 3º do art. 88 desta Lei”.

¹⁵ “Art. 37. [...] XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações”.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Gabinete da Conselheira CRISTIANA DE CASTRO MORAES



existentes no mercado.

Não obstante e conforme acenado pela própria Administração, inexistente restrição de ordem técnica impeditiva da comprovação da capacidade técnica por intermédio dos atestados de fornecimento de lâmpadas a vapor ou de outra complexidade similar ao objeto.

Essa solução amplia em tese o universo de empresas eventualmente qualificadas para execução do correspondente contrato, contribuindo de forma positiva para a competitividade da licitação.

No mais, a jurisprudência deste Tribunal também é firme na tese de que a aceitação apenas de desempenho prévio em iluminação pública, em detrimento de instalações em empreendimentos particulares (como centros comerciais, condomínios, estacionamentos etc.), configura estipulação de prova de experiência em atividade específica, em desapreço à Súmula n. 30¹⁶.

Assim foi decidido nos recentes Exames Prévios de Edital TC-015224.989.23-6 e outros (E. Pleno de 30/08/2023 e TC-011903.989.23-4 e outro (Sessão Plenária de 06/09/2023).

Sendo assim, cabe à Origem eliminar excessos da qualificação técnica, de sorte a não denotar aceitação de expertises exclusivamente em ambiente público e com luminárias de tecnologia LED.

Também não há como se afastar da verificação empreendida pela unidade de Engenharia de ATJ, concludente pela parcial procedência do reclamo direcionado contra a imposição de demonstração de realização anterior, pelo licitante, de *operação e manutenção de rede de iluminação pública com, no mínimo 2.198 (dois mil cento e noventa e oito), pontos de iluminação instalados concomitantes, com fornecimento de mão de obra e da integralidade dos materiais* (subitem 14.4.1.1).

Deveras, infere-se da manifestação técnica correlacionada que o fornecimento de mão de obra e materiais é inerente às tarefas de operação e manutenção da rede de iluminação, essas, por sinal, equivalentes ao cerne do presente anseio de contratação, razão por que a reunião dessas atividades, em dispositivo editalício único, para fins de prova de aptidão técnica, não merece ser rechaçada.

¹⁶ “Súmula n. 30 – Em procedimento licitatório, para aferição da capacitação técnica poderão ser exigidos atestados de execução de obras e/ou serviços de forma genérica, vedado o estabelecimento de apresentação de prova de experiência anterior em atividade específica, como realização de rodovias, edificação de presídios, de escolas, de hospitais, e outros itens”.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Gabinete da Conselheira CRISTIANA DE CASTRO MORAES



De todo modo, ainda em harmonia com o exposto por ATJ-Engenharia, a expressão “integralidade” deve ser retirada da cláusula em comento, com o intuito de evitar interpretações potencialmente restritivas, mormente *porque somente se deve requerer experiência nos materiais essenciais ao núcleo do serviço, visto que alguns itens acessórios (como materiais de consumo) são normalmente subcontratados*¹⁷ [...].

Ainda no que toca a esse tópico, em linha com SDG, leitura do subitem 14.4.1. combinada com a do 14.4.2.¹⁸, *que trata da admissibilidade do somatório de atestados para comprovação das atividades e quantitativos*, permite concluir que não prospera o argumento do Representante *no sentido de que, mesmo no caso de consórcios, cada empresa deveria apresentar um único atestado para todos os serviços, já que não seria admitida a comprovação de experiência “fracionada”*.

A despeito disso, recomenda-se que o Município esclareça essa temática de maneira a evitar incertezas por parte de potenciais interessadas em participarem da disputa, para assegurar, assim, atendimento ao princípio da competitividade; bem como retifique o subitem 14.4.1.1., a fim de que não apenas empresas que tenham expertise em rede de iluminação pública, mas também aquelas que a detenham na privada possam acorrer à competição.

Em continuação, convergente instrução dos autos confirmou a incorreção aventada por ocasião da determinação de suspensão deste torneio, consistente na adoção, como base de cálculo do capital social ou patrimônio líquido

¹⁷ Nesse diapasão, oportuno consignar que a minuta contratual (subitem 25.1.) permite a subcontratação e/ou contratação com terceiros para a execução dos investimentos obrigatórios, adicionais e serviços.

¹⁸ “14.4.1. A LICITANTE ou ao menos uma das CONSORCIADAS deverá comprovar, por meio de atestados emitidos por entidades públicas ou privadas, sua expertise, para execução de atividades com características técnicas similares e de maior relevância às atividades operacionais, no âmbito da CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, quais sejam:

[...]

14.4.2. **Será admitido o somatório de atestados para comprovação das atividades e quantitativos** elencados nos subitens acima, sendo que, com relação aos quantitativos, pelo menos 1 (um) atestado deve representar 50% (cinquenta por cento) do quantitativo mínimo exigido”.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Gabinete da Conselheira CRISTIANA DE CASTRO MORAES



que deverá ser demonstrado, na seara da aptidão econômico-financeira¹⁹, do montante estimado do contrato, obtido a partir do somatório das quantias máximas previstas para a contraprestação durante toda a vigência da avença²⁰ – e não da quantia equivalente aos investimentos a ser despendidos pela futura concessionária, esses, segundo apurado pela Área Especializada em Economia desta Casa, de aproximadamente R\$ 8.864.946,00²¹, de forma que o instrumento não se coaduna com a orientação jurisprudencial prevalente nesta Casa, exemplificada pelo julgamento do Processo n.º TC-011912.989.20-9, em Sessão Plenária de 22/07/2020, sob relatoria do e. Conselheiro Antonio Roque Citadini.

Nessa direção, especificamente sobre a base de cálculo do capital mínimo ou patrimônio líquido, dada a coincidência da redação do artigo 69, § 4º, da Lei n.º 14.133/2021²² com a do artigo 31, § 3º, da Lei n.º 8.666/1993²³ em tal ponto, incide na espécie, por analogia, o teor do Enunciado Sumular n.º 43 deste Tribunal, nos moldes da análise efetuada por ATJ-Economia:

[...] De minha parte, reforço que esta Casa já se posicionou quanto à utilização do montante de “investimentos”, como base de cálculo para os requisitos de qualificação de qualificação econômico-financeira nas licitações para concessões. Aliás, este é o entendimento preconizado na Súmula nº 43 desta Corte, que muito embora faça alusão a licitações para

¹⁹ “14.2.11. As LICITANTES deverão comprovar, em ambos os balanços patrimoniais e demonstrações financeiras, que têm patrimônio líquido ou capital social mínimos em montante equivalente a 10% (dez por cento) do valor estimado do contrato, conforme cláusula 5.1. Em se tratando de CONSÓRCIO, aplicar-se-á o acréscimo de 30% (trinta por cento) previsto no § 1º do art. 15, da Lei Federal nº 14.133/2021. Casa CONSORCIADA deverá apresentar, individualmente, patrimônio líquido ou capital social igual ou superior ao produto da multiplicação do percentual de sua participação no CONSÓRCIO e do patrimônio líquido ou capital social mínimos exigidos para CONSÓRCIOS”.

²⁰ “5. DO VALOR ESTIMADO DO CONTRATO

5.1. O valor estimado do CONTRATO é de \$ 67.500.000,00 (sessenta e sete milhões quinhentos mil reais), que corresponde ao somatório dos valores máximos previstos para CONTRAPRESTAÇÃO”.

²¹ Informação extraída por ATJ-Economia do documento inserido no Evento 23.12, fl. 84.

²² “§ 4º A Administração, nas compras para entrega futura e na execução de obras e serviços, poderá estabelecer no edital a exigência de capital mínimo ou de patrimônio líquido mínimo equivalente a até 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação”.

²³ “§ 3º O capital mínimo ou o valor do patrimônio líquido a que se refere o parágrafo anterior não poderá exceder a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação, devendo a comprovação ser feita relativamente à data da apresentação da proposta, na forma da lei, admitida a atualização para esta data através de índices oficiais”.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Gabinete da Conselheira CRISTIANA DE CASTRO MORAES



concessão de serviço público de transporte coletivo de passageiros, pode ser aplicada por analogia ao caso concreto, tendo em vista também se referir a uma concessão pública.

SÚMULA Nº 43 – Na licitação para concessão do serviço público de transporte coletivo de passageiros, os requisitos de qualificação econômico-financeira devem ter como **base de cálculo o valor dos investimentos devidos pela concessionária.** (g.n.)

Nessa direção, e por se tratar de reclamação similar, trago à colação excerto de interesse, extraído dos autos do TC-13763.989.20-9 e outros, em voto proferido pelo Exmo. Conselheiro-Substituto Alexandre Manir Figueiredo Sarquis, Tribunal Pleno, Sessão de 22/07/2020, também em exame prévio de edital:

“E a respeito desses pressupostos de qualificação econômica, há de ser procedida uma retificação nos valores fixados pelos itens 17.1323 e 17.1624 do edital ao capital social mínimo e à garantia de participação, vez que, na atual redação, o capital social fora fixado em valor correspondente a 12 (doze) parcelas da contraprestação mensal e a garantia em 1% do valor estimado do contrato, **o que se revela incompatível com pacífica jurisprudência há tempos consolidada no âmbito das concessões de serviços públicos, pelo emprego dos investimentos previstos como a base de cálculo desses requisitos de qualificação econômica.**

Não obstante a tese da defesa ter se baseado no fato de a redação da Súmula nº 43 deste Tribunal estar direcionada a serviço público de transporte de passageiros, não há como deixar de considerar que as bases desse enunciado se transmitem à concessão de outros serviços públicos a exemplo do presente, onde há, igualmente, demandas por investimentos que constituem a gênese do juízo discricionário pela delegação dos serviços em questão, sendo que tais demandas por investimentos é o objeto jurídico que os requisitos de qualificação econômica buscam preservar.

Em outras palavras, não se exige patrimônio líquido ou capital social mínimo para assegurar as receitas estimadas da concessionária, as quais compõem o valor do contrato e as 12 contraprestações mensais. E o mesmo se dá em relação à garantia de participação.

Deverão ser retificados, portanto, os itens 17.3 e 17.6 do edital, para que os valores exigidos do capital social mínimo e da garantia de participação passem a ser calculados com base no valor total estimado para os investimentos”. (g.n.)

Também nesse sentido, os julgados abrigados nos TCs-23256.989.19-5, 20472.989.20-1, 14367.989.21-7, 9283.989.23-4 e 6240.989.23-6, os quais também se deram em sede de exame prévio de edital.

Logo, determinante que o Município modifique o subitem 14.2.11. do instrumento de convocação, com o intuito de que o parâmetro para o cálculo do patrimônio líquido ou capital social mínimo seja estabelecido em relação ao montante de investimentos que deverão ser feitos pela Concessionária.

Por derradeiro, à vista do parecer do Ministério Público de Contas, impende asseverar a Origem para a necessidade de exclusão da alínea “e” do



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Gabinete da Conselheira CRISTIANA DE CASTRO MORAES



subitem 7.2., bem como do subitem 14.2.5., e de retificação do subitem 14.2.2., pois a dicção do artigo 69, inciso II, da Nova Lei de Licitações e Contratos permite apenas a solicitação de certidão negativa de feitos sobre falência, não abarcando mais aquelas inerentes a recuperação judicial e extrajudicial, na esteira do já decidido nos autos do TC-022249.989.24-5²⁴ (Sessão Plenária de 04/12/2024, sob minha relatoria).

Nessa conformidade, nos estritos limites dos aspectos abordados, meu voto considera **parcialmente procedente** a Representação intentada por **Rafael Augusto Prodóssimo da Silva**, **sem prejuízo das recomendações constantes do corpo do presente voto**, para determinar que a **Prefeitura Municipal de Brodowski** altere o edital da **Concorrência Pública n.º 003/2023**, **Processo n.º 0596/2023**, de forma a:

- a)** no tocante à qualificação técnica: **a.1)** eliminar excessos do subitem 14.4.1.2., de sorte a não denotar aceitação de expertises exclusivamente em ambiente público e com luminárias de tecnologia LED; e **a.2)** retirar do subitem 14.4.1.1. a expressão “integralidade”, em conformidade com ATJ-Engenharia; e
- b)** alterar a base de cálculo do patrimônio líquido/capital social mínimo (subitem 14.2.11.), passando a adotar o valor total dos investimentos previstos.

²⁴ “[...] Prossequindo, mostra-se necessária a revisão das cláusulas 15.1.3.1. e 15.1.3.4., bem como exclusão do subitem 15.1.3.3 do ato de chamamento, porquanto a solicitação de certidão negativa de recuperação judicial (e, em caso de certidão positiva, de apresentação do respectivo plano ou, se o caso, do extrajudicial), em que pese o disposto na Súmula n.º 50 deste Tribunal, não se coaduna com a dicção do artigo 69, inciso II, da Nova Lei de Licitações e Contratos de 2021, cujo teor permite apenas a requisição de certidão negativa de feitos sobre falência, expedida pelo distribuidor da sede do licitante.

Tal entendimento decorre do julgamento dos processos TC-014069.989.23-4 (Sessão Plenária de 16/08/2023, sob relatoria do e. Conselheiro Edgard Camargo Rodrigues), TC-001390.989.24-2 (Sessão Plenária de 22/05/2024, sob relatoria do e. Conselheiro Robson Marinho), TC-018450.989.24-9 (Sessão Plenária de 06/11/2024, sob relatoria do e. Conselheiro Marco Aurélio Bertaiolli) e TC-021736.989.24-5 (Sessão Plenária de 27/11/2024, sob relatoria do e. Conselheiro Dimas Ramalho)”.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Gabinete da Conselheira CRISTIANA DE CASTRO MORAES



Após proceder às alterações do instrumento, os responsáveis pelo certame deverão atentar para o disposto no §1º do artigo 55 da Lei Federal n.º 14.133/2021, com nova publicação e reabertura de prazo para formulação de propostas.

Expeçam-se os ofícios necessários, encaminhando os autos, após o trânsito em julgado, para arquivamento.

É como voto.